

1501116-54.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... e R\$ 25; o denunciado confessou o tráfico aos policiais; a quantia e a forma de acondicionamento da droga apreendida, além das circunstâncias da prisão, demonstram a finalidade de narcotráfico. Notificado, o réu apresentou resposta à acusação. (fls.122/125) A denúncia foi recebida em 27/05/2022 (fl.127). Nesta data foi feita a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501116-54.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143049/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 25194803 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2143049 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI HENRIQUE SILVA GABRIEL DE FREITAS

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

11/07/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 11 de julho de 2022, às 15h15, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Dr. Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, o réu Davi Henrique Silva Gabriel de Freitas, apresentado para a teleconferência através da Penitenciária de Assis, seu advogado, Dr. José Roberto Magalhães OAB/SP 353.632, e as testemunhas Rodrigo Cintra Nunes, Vinicius Rodrigues Torniche e Reginaldo Santana. Iniciados os trabalhos, procedeu-

se ao interrogatório do acusado, a oitiva das testemunhas e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida sentença: Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Davi Henrique Silva Gabriel de Freitas, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 33, "caput", com a causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006. Narrou que no dia 25 de maio de 2022, por volta das 17h15min., na Avenida Vereador David Passarinho, nº. 998, Vila Souza, nesta cidade e Comarca, Davi Henrique Silva Gabriel de Freitas, trazia consigo cerca de 50,50g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, Davi mantinha em sua posse cerca de 50,50g de maconha, embalada em porções de tamanho razoável; o denunciado estava na "Praça da Prudenciana", local este conhecido como ponto de compra e venda de entorpecentes; policiais tinham informações de atividades ilícitas no referido local; visualizaram ele vender drogas a três pessoas; fizeram abordagem e em realizarem revista pessoal encontraram 18 porções de maconha e R\$ 25; o denunciado confessou o tráfico aos policiais; a quantia e a forma de acondicionamento da droga apreendida, além das circunstâncias da prisão, demonstram a finalidade de narcotráfico. Notificado, o réu apresentou resposta à acusação. (fls.122/125) A denúncia foi recebida em 27/05/2022 (fl.127). Nesta data foi feita a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação, sob os argumentos de que: os policiais falaram que fizeram campana e viram o réu atender três pessoas e receber dinheiro; fizeram a abordagem e constataram que o réu trazia 2 porções de maconha na mão e outras dentro da cueca; embora o número de porções não seja das maiores a quantia de droga é relevante e o tamanho não era de mero baseado; as palavras dos policiais são sólidas para a condenação e eles narraram a confissão espontânea de Davi; a versão do réu não merece a mínima credibilidade; deve ser aumentada a pena pelo fato ter sido praticado numa praça; deve ser fixado o regime inicial fechado pela natureza hedionda e o crime ser concretamente grave pela relevante quantia de droga e ser numa praça; deve ser decretado o perdimento do dinheiro e ser mantida a prisão preventiva. A douda Defesa pleiteou a absolvição do réu, sob as alegações de que: o réu sustentou que a droga era destinada ao uso exclusivo; os policiais não informaram no depoimento que havia denúncias; um policial falou ter visto entregarem dinheiro ao réu e o segundo disse que estava fechado na mão dessa pessoa, a indicar contradição; o réu foi ao local comprar maconha por ser usuário; é um ponto de venda; os policiais não abordaram nenhum destes usuários; a palavra dos policiais não é suficiente para provar e a palavra do réu tem a mesma credibilidade que a deles; não é verdade que o réu confessou a traficância; os supostos clientes não apareceram; não há prova do tráfico de drogas; deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo; a quantia de drogas apreendida com o réu é pequena e não havia materialidade; deve ser desclassificada a conduta para posse de drogas para uso próprio; no caso de condenação deve reconhecer o tráfico privilegiado e ser fixado o regime inicial aberto. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é procedente. A materialidade do delito de tráfico ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), boletim de ocorrência (fls. 14/15), auto de exibição e apreensão (fls.18) e laudo de pericial (fls.23/25). Extraí-se do laudo pericial (fls.108/110) que foram periciados fragmentos vegetais, com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC), cuja substância é contida em lista proibitiva no Brasil. A autoria também é certa e atribuída ao acusado, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Em seu interrogatório Davi negou o crime.

Afirmou que a droga era sua, para seu consumo. Relatou que pagou R\$ 120 nessa droga. Mencionou que é usuário de maconha desde os 12 anos e usa de 5 a 7 porções por dia. Declarou que compra sempre em quantia grande, em caroço, eles lhe deram o "picuá" e colocam no bolso. Salientou que disse aos policiais que estava no seu bolso. Negou ter visto a campana e ficou parado quando os viu. Falou que foi nessa praça para comprar pagou R\$ 120 e em questões de segundo a Rocan chegou. Narrou que estava com Mateus e outro rapaz. Negou ter confessado o tráfico aos policiais. Frisou que o dinheiro é proveniente de seu trabalho na pizzaria. Esclareceu que não passaram 5 minutos entre comprar a droga e os policiais chegarem. Falou que na verdade foram poucos segundos entre a pessoa entregar o objeto e a abordagem. Enfatizou que os policiais viram a compra da droga e falou a eles que tinha acabado de comprar. Contou que os policiais já o abordaram uma vez antes e não encontraram, mas ameaçaram que na próxima vez o levariam. Afirmou que essa abordagem ocorreu três dias antes. Negou que estas pessoas tenham corrido quando os policiais chegaram, ficaram no mesmo lugar. Relatou que estava com outro rapaz comprando e outro lhes vendeu. Mencionou que trabalhava de forma "freelance" para o Reginaldo e trabalhava por três dias durante a semana. Narrou que recebia R\$ 70 por dia. Negou ter passagem. A testemunha Rodrigo afirmou que sempre tinha denúncias de tráfico num parque, onde os pais brincam com filhos, várias pessoas denunciaram que havia tráfico nesse horário. Relatou que fizeram breve observação e já tinham denúncias do Davi. Mencionou que conseguiram ver com um celular que ele pegava droga de dentro da cueca e entregava a pessoas, viram ele entregar a três indivíduos. Declarou que conseguiram abordá-lo e durante a revista na mão direita dele havia 2 porções de maconha, envoltas em papel filme. Falou que acharam 25 reais em notas picadas, com ele, e dentro da cueca tinha mais uma porção grande envolta em papel filme, contendo 16 porções de maconha. Frisou que ele admitiu que estava traficando. Contou que estas três pessoas entregaram dinheiro ao réu. Esclareceu que estava a 50 metros do réu, era durante o dia e estava claro. Ressaltou que havia várias denúncias contra o réu naquele local. Narrou que lá fica uma quadra poliesportiva e vários pais levam os filhos para brincar. Negou ter sido possível abordar estas outras pessoas, pois quando abordaram o réu eles fugiram. Negou ter apreendido com o réu objeto utilizado para consumir a droga. Afirmou que houve denúncias de tráfico de drogas nesse dia dos fatos, inclusive contra Davi. Relatou que já abordou o réu nesse local antes dos fatos, não se recorda especificamente quando, nada localizou. Mencionou que estas pessoas entregaram notas picadas, de 5 e 10 reais, as drogas o réu tirava da cueca. Mencionou que o foco era o réu vendendo drogas, não as outras pessoas, estavam em dois patrulheiros e já tinham denúncias de Davi. Tais informações foram confirmadas pelo policial Vinicius. Confirmou ter feito campana e ter visto o réu servindo três pessoas. Relatou que fez a abordagem, o réu estava com 2 porções de maconha na mão e primeiro falou que era para uso próprio, mas depois que acharam as 16 porções de droga na cueca o réu admitiu que estava traficando. Mencionou que era uma praça e havia vários pais brincando com os filhos, esses pais falavam sobre o tráfico na praça, mas ficavam com receio de apontarem os traficantes. Declarou que abordou o réu uma vez, mas nada localizou com ele. Frisou que a pessoa colocava alguma coisa na mão do réu, ela recebia algo e já ia embora, aparentava ser dinheiro pelo volume. Narrou que o réu estava com R\$ 25. Negou ter conseguido ver a cédula, normalmente entregam dobrada. A testemunha Reginaldo afirmou que conheceu o réu há dois anos, trabalhou com o depoente e saiu, voltou a trabalhar e saiu dois dias antes. Relatou que ele trabalhava cortando massa de pizza e era funcionário do depoente. Mencionou ter boatos de que o réu usava drogas, mas dentro da pizzaria não tem. Negou ter fato que desabone a conduta do réu. Negou ter tido informação de que o réu traficava, o comportamento dele era 100%. Pois bem. De acordo com o relato dos policiais eles receberam notícias de tráfico de droga na praça da Prudenciana, inclusive indicando o réu como um dos traficantes. Fizeram breve campana e visualizaram gestos típicos de venda de drogas. O policial Rodrigo contou que viu Davi atender três pessoas, ele pegava droga de dentro da cueca, entregava a elas e recebia dinheiro em troca. No mesmo sentido foi o relato do policial Vinicius, com a exceção que não conseguiu distinguir que o réu recebia dinheiro destas pessoas.

Esta contradição pode ser explicada porque a capacidade visual pode variar de uma pessoa para outra e não houve distinção quanto ao que realmente importa, que é a movimentação típica de tráfico de drogas, consistente na troca de objetos e as pessoas saindo do local. Corrobora a versão dos policiais o fato deles terem apreendido 2 porções de maconha nas mãos de Davi, mais R\$ 25 em notas diversas e mais 16 porções de maconha dentro da cueca dele. Embora o réu tenha negado a traficância e tenha sustentado que estava lá apenas para usar entorpecentes esta versão não convence. Isso porque os policiais o viram atender a três pessoas e trocar objetos com elas, uma movimentação que é típica de venda de drogas que não foi explicada pelo réu no interrogatório. Com a devida vênua ao combativo Advogado, não é exigível que houvesse a abordagem desses usuários. Primeiro porque os policiais estavam em apenas dois e jamais iriam se separar, deixando apenas um para abordar o suspeito de um crime. Segundo porque é natural que pessoas tenham receio de depor contra traficantes. Ressalto que os depoimentos dos policiais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas que teriam ensejado a prisão do réu. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais incumbidos do dever da repressão penal (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263). Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais ou guardas civis. Não há elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o réu e não se pode desmerecer a fala só por pertencerem aos quadros da Polícia. Foram submetidos ao contraditório como qualquer testemunha. Seria contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção da criminalidade e negar-lhe esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta de suas atividades. Guilherme de Souza Nucci leciona sobre a validade dos depoimentos dos policiais: "(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas, 2ª ed., São Paulo: RT, 2007, p.323). Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j.05.09.06 DJU 16.02.07, destaquei). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p.39.846, destaquei). Na mesma linha é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE. [...]. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS OFENDIDOS. VALIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOBSERVÂNCIA. [...] 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada. (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.2011, destaquei). HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33, DA LEI N.º 11.343/06, 304 E 333, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. [...] (STJ HC 149.540/SP 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.2011 DJU 04.05.2011, destaquei). "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos". (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013, destaquei). No caso concreto observo que os policiais prestaram a mesma versão, harmônica e uníssona, todas as vezes em que foram ouvidos. É absurdo supor que os policiais optariam por deixar livre o verdadeiro traficante para prender um inocente. Por outro lado, a versão do réu restou isolada nos autos. Ele falou em Juízo que estava com Matheus e outro indivíduo, mas não trouxe uma única pessoa na audiência para testemunhar que a abordagem policial se deu de outra forma. Tampouco trouxe algum motivo concreto para os policiais virem em Juízo mentir e acusá-lo injustamente da prática do crime. O fato objetivo é que pela prova produzida efetivamente o réu tinha a posse destas 18 porções de maconha, já individualizadas e prontas para a venda, entregou a usuários e ainda tinha em seu poder R\$ 25 em dinheiro, cuja origem lícita não foi provada. Assim, deve ser decretado o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, do CP c.c art. 63 da Lei n.º 11.343/06. Nesse mesmo sentido, cite-se o seguinte julgado: Inexistindo a prova da origem lícita e havendo presunção de que os bens pretendidos eram produto da prática do tráfico, não há falar em restituição, apresentando-se correta a decretação de perdimento dos bens em favor da União, na forma delimitada pelo art. 60 e § 1º, c/c art. 63 da Lei nº 11.343/06 (TJMG, Apelação Criminal nº 2.0040.08.072861-7/001(1), 4ª Câmara Criminal, Rel. Walter Pinto da Rocha. j. 28.01.2009, unânime, Publ. 11.02.2009, destaquei). Além disso, extrai-se dos relatos dos policiais que Davi confessou a eles o tráfico de entorpecentes e que havia denúncias de tráfico por ele nesse mesmo local. Por fim, sabe-se que, não raro, usuários de drogas acabam atraídos para o comércio nefasto até como uma forma de subsidiar o vício. Porém, a desclassificação pretendida só é admitida quando se comprova que a posse do entorpecente se destina, exclusivamente, a consumo próprio, situação que não se verifica neste caso concreto. As evidências de que existiram atos ilícitos de posse para mercancia não podem ceder lugar para a posse de drogas para uso próprio. Portanto, não obstante os argumentos deduzidos pela Defesa, as evidências de que existiram atos ilícitos não podem ceder lugar para a posse de substância entorpecente para uso próprio. O réu pode até ser usuário de drogas, mas deve prevalecer, para fins penais, no caso em tela, a conduta descrita no tipo que define o crime de tráfico, mais gravosa perante a sociedade, por não ter sido provado que as drogas eram destinadas exclusivamente ao uso próprio. Não apresentou um único motivo para estar numa praça com 50g de maconha. Davi sequer trazia consigo algum petrecho relacionado ao uso de drogas. Assim, não é possível

desclassificar a conduta para o porte de drogas para o uso próprio, como pretendido. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, se o agente realiza o crime nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. A jurisprudência das Cortes Superiores é tranquila no sentido de que esta causa de aumento de pena é objetiva, de modo que basta o tráfico nas imediações destes locais, sendo irrelevante que o agente visar ou não os frequentadores. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados: Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional. Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 138944, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j.21/03/2017, publ. 03/08/2017). “a comercialização de drogas nas dependências ou nas imediações [de estabelecimentos prisionais], por si só, já justifica a incidência da causa especial de aumento de pena, sejam quais forem as condições subjetivas do agente que a comete” (HC nº 114.701/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13). “O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local” (HC nº 116.929/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/11/13). “o espírito, ao que transparece, foi o de punir com maior rigor aquele que, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas, aqui incluídos quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não apenas o comércio, justamente porque em locais como tais, mais fácil é ao traficante passar despercebido à fiscalização, sendo maior, consequentemente, a reprovabilidade de sua conduta” (AgRg no Resp 1346137/SC, Sexta Turma, Rel.^a Min.^a Maria Thereza De Assis Moura, j. em 10.06.2014). CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLAS E IGREJAS. CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA PRATICADO NAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES OU QUE OS ENTORPECENTES SE DESTINAVAM AOS SEUS FREQUENTADORES. 1. A jurisprudência deste sodalício firmou-se no sentido de que a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação do tráfico nas entidades nela mencionadas, ou mesmo que o comércio proscriito destina-se a atingir os seus frequentadores, bastando que o crime tenha sido cometido em locais próximos a tais estabelecimentos, o que afasta a coação ilegal suscitada na impetração.(...) (Habeas Corpus nº 443828/SP, 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. DJe 20.06.2018). No caso dos autos ficou demonstrado que o requerido realizou a traficância na praça da Prudenciana, o que basta para a caracterização desta causa de aumento. Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo. Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e

60 do Código Penal, passo a dosagem das penas, eis que não milita em favor do réu qualquer dirimente: A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, é normal para a espécie. É primário e não ostenta maus antecedentes. Não há informação acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. Os motivos e circunstâncias foram inerentes ao tipo. Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a considerar. Na terceira fase restou configurada a causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, conforme fundamentação supra. Aumento a pena em 1/6 (um sexto) e a fixo provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Deve ser aplicada a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de maus antecedentes e de indícios de que se dedique a atividades criminosas e integre organização ilícita. Não vejo inconstitucionalidade neste dispositivo, pois o legislador quis tratar de maneira menos rigorosa o traficante ocasional; houve exasperação da pena para o tráfico em comparação com a antiga Lei nº 6.368/76, de modo que não se justificava um tratamento igualitário entre o traficante profissional e o eventual. Está aí a razão da causa de diminuição em apreço, apta a realizar (e não a maltratar) o princípio da isonomia. O teste de constitucionalidade, à luz do princípio da isonomia, deve ser realizado no âmbito do microssistema da Lei de Drogas, não se podendo fazer comparações com outros crimes previstos na legislação penal. Para a definição do total de diminuição da pena deve ser levando em conta a quantidade de droga apreendida e a potencialidade lesiva da mesma. Este é o posicionamento da jurisprudência majoritária e foi respaldado em recente julgado da 1ª Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão adiante colacionado aos autos: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO TERATOLÓGICA A ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO PELO RECURSO CABÍVEL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E AUMENTADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM 1/6 (UM SEXTO) EM DECISÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NA DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. A causa especial de diminuição de pena de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada em apenas 1/6 (um sexto), num intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), com fundamento na quantidade de entorpecente, que é critério preponderante fixado na lei, revelando a justeza da sanção no caso concreto. Precedentes: HC 98.900, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2010 e HC 94.559, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 04/11/2010). (...) (STF, HC 104195, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, j.26/04/2011, destaquei). No caso houve a apreensão cerca de 50g de maconha. Assim, levando em conta a relevante quantidade e a espécie do entorpecente apreendido considero que a diminuição deve ser limitada a 1/3 (um terço) e atinge a pena o montante de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo, em face da renda apurada no interrogatório e do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, valor que deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi da relevante quantia de droga traficada e do fato de vender drogas numa praça, o que indica maior gravidade da conduta, do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e da regra constitucional prevista no art. 5º, inc. XLIII da Constituição Federal, e de uma política criminal mais rigorosa de repressão aos crimes de tráfico. Justifico a fixação do regime prisional mais gravoso, a não substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena também pelo fato de estarem ausentes os requisitos dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em

regime fechado, seja porque o art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI, da Carta Magna. Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário;

já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no art. 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. Orig. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.09). O crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Nesse aspecto, acerca da necessidade do regime mais grave para o tráfico de drogas, cito o voto do eminente Desembargador Machado de Andrade, no julgamento da Apelação nº 0004588-12.2016.8.26.0189, julgado em 21/09/2017: "Esse desgraçado vício da cocaína chegou em nosso país e, principalmente, nessa cidade de São Paulo, onde todo mundo sabe que existem logradouros públicos, que foram praticamente tomados por viciados. É bom lembrar que o usuário de cocaína quando não tem dinheiro para adquirir a cocaína pura, que é em forma de pó, passa a se utilizar de uma forma inventada nos Estados Unidos, mais, precisamente na cidade de Nova York, no início dos anos 1970, denominada crack, aliás muito mais potente no sentido de fazer com que apenas com uma aspiração da fumaça tóxica (coloca-se a pedra em um pequeno cachimbo, conhecido como "marica", geralmente de vidro, esquentando-se embaixo com uma chama de isqueiro ou fósforo, e a pessoa suga a fumaça que desprende da pedra de "crack") já se torna dependente desta desgraça que foi inventada por indivíduos alheios a qualquer sentimento de piedade e que tinham somente interesse em ganhar dinheiro. Ora, uma pessoa que transforma seu semelhante num morto vivo, ou seja, um verdadeiro zumbi, como os que se vê na mídia, principalmente televisiva, indivíduos convivendo juntos na maior sujeira e promiscuidade, sendo que os locais onde essas pobres almas habitam, tem que ser constantemente lavado, com jatos de água e detergentes, pela Prefeitura Municipal, a fim de remover o fedor que exala do chão devido às secreções e excrementos que essas pessoas deixam naqueles locais. Tudo o que disse acima, e que é do conhecimento de todos, acontece por apenas uma razão, devido à ação de pessoas destituídas de qualquer sentimento de amor ao próximo, como é o caso do traficante e, nesses autos, do acusado. Com relação à conduta social do recorrente, não há qualquer dúvida que, com sua atividade de traficantes, ele causou um mal irreparável à sociedade, uma vez que muitos adolescentes, provavelmente, foram por ele jogados no inferno de uma vida de usuário de drogas. O direito, como é cediço, é uma ciência mutável, ou seja, ele tem que acompanhar a evolução humana, e se adaptar às suas necessidades que mudam a cada época do desenvolvimento da sociedade. Assim sendo, como uma das finalidades da pena é intimidar um possível criminoso, é mais do que óbvio que um crime como o tráfico de drogas, que, sem falar nos males causados à pessoa humana, abre as portas para inúmeros outros delitos, como furtos, roubos, homicídios, prostituição etc.; não pode receber um tratamento menos gravoso do que um delito de menor potencial ofensivo. Assim, ante o terrível mal que o réu causava à sociedade antes de ser preso não há outro regime, senão o inicial fechado, como forma de contraprestação do Estado à sua conduta. Fixar-se um regime mais benéfico do que o inicial fechado, seria conceder-se uma benesse ao réu, a qual ele não é merecedor". No mais, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta cidade. Por fim, a Lei nº 12.736/2012 deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o

de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Pelo art. 1º: "a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei". Já o art. 2º acrescenta o § 2º ao art. 387 do CPP: "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração. Neste caso concreto o réu não cumpriu 2/5 da pena, de modo que não faz jus à progressão. Assim, apesar da detração ora realizada, o regime inicial de cumprimento da pena restante ainda será o fechado. Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR o réu Davi Henrique Silva Gabriel de Freitas, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, c.c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita porque se trata de réu pobre; c) DECLARAR a perda, em favor da União, do numerário apreendido nestes autos, com base nos arts. 91, inc. II, do Código Penal, e 63, da Lei nº 11.343/06. Uma vez que se cuida de réu que viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar e traficava relevante quantidade de droga, a indicar periculosidade, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e as jurisprudências que adoto como razão de decidir, in verbis: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHCnº111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013). "(...) Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...) " (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei). Recomende-se o réu no local onde está detido, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional. Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas. Sentença registrada eletronicamente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Decorrido o trânsito em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Expeça-se ofício ao Banco do Brasil solicitando que efetue a transferência do valor em favor do FUNAD, constando como CNPJ do favorecido o nº 02.645.310/0001-99, banco 001, agência 1607-1, c/c 170500-8, código identificador nº 2002460000120201, e o envio de comprovante nos autos, no prazo de 10 dias; 5) Expeça-se ofício à SENAD, encaminhando cópia do auto de apreensão de bens, sentença de perdimento, certidão do trânsito em julgado e comprovante do depósito, para ciência. Envie-se-o pelo e-

mail cdc.funad@mj.gov.br; 6) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 7) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribua ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva". Em seguida, o(a)(s) Defensor(a)(es), o(s)réu(s) manifestou(aram) o desejo de recorrer contra a sentença proferida nesta data. Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos.1. Recebo o recurso interposto pelo(a) defensor(a). Sai o(a) Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões no prazo de 8 (oito) dias. 2. Se não forem apresentadas razões no prazo pela Defesa, intime-se para apresentar no prazo de 24 horas. 3. Se não fizer, intime-se o réu para constituir novo Advogado no prazo de 10 (dez) dias, com a advertência de que se não o fizer será nomeado Advogado Dativo. 4. Decorrido o prazo, nomeie Defensor Dativo junto à OAB e intime-se-o para apresentar as razões recursais no prazo legal. 5. Após a apresentação, abram-se vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias; 6. Extraia-se a guia de execução provisória e remeta-se à VEC competente. 7. Por fim, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo(s) sentenciado(s), observando-se as formalidades legais. Considerando a pena imposta, anoto que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 10 de julho de 2030. Saem os presentes intimados". Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça de São Paulo. Eu, Antônio Celso Sanches, digitei.